

0034375-81.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... droga encontrada em poder do réu era para fins de tráfico.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas em poder do réu não deixam dúvidas de que serviam para o tráfico de drogas.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0034375-81.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0034375-81.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 1368/2017 - 30º Distrito

Policial - Tatuapé, 251/2017 - 30º Distrito Policial - Tatuapé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTEMAR MACHADO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº1145/21

VISTOS.

VALTEMAR MACHADO SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque consta que no dia 27 de abril de 2017, por volta das 19h, no bar "Altas Horas", situado na Avenida Itaquera, nº 100, nesta cidade e comarca, guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 35 microtubos de cocaína (massa líquida: 16,4 gramas) com a intenção de entrega rápida ao consumo de terceiros

A denúncia foi recebida às fls. 269/270.

Defesa preliminar às fls. 288/319.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo,

duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, em memoriais a fls 354/370, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de uso, aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33, com pena mínima e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva veio bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 24/26, dando conta dos 35 invólucros contendo cocaína, além dos R\$ 26,00 em espécie e demais objetos pessoais, localizados e apreendidos em poder do réu.

Em complementação, o Exame Químico Toxicológico de fls. 31/32, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para cocaína.

A autoria também é inconteste.

Os argumentos da Douta Defesa não arredaram os fortes indícios e provas diretas que derivaram contra o réu, em especial, pelos laudos periciais, testemunhas inquiridas e declaração do próprio acusado, que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia, o réu permaneceu em silêncio. Ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu declarou que eu tenho esse bar desde 2004, e no dia dos fatos os policiais chegaram lá, com um veículo corsa, pararam na calçada, puxaram as armas e foram me algemando. Eu indaguei o motivo, sendo que eles nem tinham entrado no bar. Eles disseram que era uma denúncia de tráfico. Eles chamaram o GOE, sem motivo, não tinha ninguém armado. Eles entraram no bar, fizeram a revista, chegaram também policiais militares, que foram embora. Atrás do balcão tinha uma impressora, onde eles acharam mesmo a droga, que de pronto eu confessei que era minha. Porém não ofendi os policiais, as drogas eram para meu uso e não para venda, tanto que os policiais não viram eu entregando nada, e nem encontraram dinheiro, porque o dinheiro que tinha era de venda do bar. Eu sou usuário, e dez pinos eu uso em uma noite. Atualmente eu não uso mais, mas na época eu usava isso; cada pino custa dez reais. Eu sou casado, e não era sempre que eu comprava essa quantidade. Não conhecia os policiais, e ainda trabalho no bar.

Ocorre porém que a tese do acusado, secundado por sua defesa, no sentido de que as drogas eram para seu uso, restou isolada e em absoluto não convenceu.

Veja que foram encontrados 45 pinos de cocaína, escondidos em uma impressora.

Embora tenha o réu dito que chegava a usar dez pinos em uma só noite, não há como se negar que 45 pinos de cocaína é quantidade muito grande para ser guardada apenas para uso. Além disso, não se pode crer que ele gastasse 450 reais na compra de drogas para seu uso.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem, ao acaso, forjar uma denúncia anônima em desfavor do réu, amealhar entorpecentes e dinheiro, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusa-lo da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Tanto que o próprio réu, em seu interrogatório, afirmou que não conhecia os policiais.

Desta feita, as justificativas do acusado, secundadas por sua defesa, no sentido de que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo que as provas dos autos apontam em sentido contrário, ou seja, que na ocasião a droga encontrada em poder do réu era para fins de tráfico.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas em poder do réu não deixam dúvidas de que serviam para o tráfico de drogas.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a forte movimentação no bar do réu, o encontro das drogas em seu bar, somado ao relato firme e seguro por

parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância. Tanto que o policial civil do GOE, que foi prestar apoio á ocorrência, Andrei Glauber de Souza Bandeira, relatou em Juízo, de forma firme e segura que sou policial do GOE e fomos prestar apoio aos policiais do 30º DP que estariam em uma ocorrência de tráfico. Ao chegarmos ao local, percebemos que estavam mesmo todos exaltados. Acalmamos o pessoal para que a equipe do 30º DP pudesse realizar as diligências. Eles entraram, encontraram as drogas e a partir daí assumiram a ocorrência. Não consigo me lembrar do réu em razão do tempo.

Confirmando a fala de seu colega, o policial civil responsável pela prisão do réu, Sandro Bonfim Real em Juízo relatou que houve uma denúncia anônima, fomos até o local, e ficamos a distancia observando a movimentação. Optamos pela entrada no local, como tinha muita gente, eles se exaltaram e ficaram agressivos, dizendo que não acreditavam que eramos policiais porque estávamos em viatura descaracterizada. O réu não deixava a revista no bar, quando pedido apoio ao GOE. Quando o GOE chegou, procedemos com a revista no bar, e localizamos as drogas no interior de uma impressora. O réu está diferente, porém se está no processo que era ele, é ele sim. Os policiais civis narraram com segurança e precisão como se deu o encontro da droga, relatando todos os detalhes, desde diligências pelo local dos fatos, o momento em que o réu tentou esconder as drogas ao avistar os policiais, sua abordagem, a confusão gerada no bar, o encontro das drogas e dinheiro em poder do réu, até final prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos.

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova.

Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos.

Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não

passou de uma armação para incriminar o réu e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo impossível a absolvição.

Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Neste contexto, em vista das drogas encontradas em poder do réu, a quantidade de dinheiro encontrado em seu poder, sua confissão sobre a propriedade das drogas, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros. Em arremate, o fato do réu ser também usuário e estar vendendo para sustentar seu vício, em nada abala a tipificação constante na denúncia. Os chamados traficantes usuários devem ser penalizados, com o mesmo rigor, uma vez que integram a cadeia do tráfico de forma fundamental, pois com o objetivo de conseguirem lucro fácil para sustentarem seus vícios, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários.

Destarte, não se evidenciou qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é primário e sem antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 279/280, de maneira que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos.

E isso porque o acusado primário, sem quaisquer antecedentes, é jovem e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a quantidade e capacidade lesiva da droga em questão, tratando-se de cocaína, substância que vem causando estragos de enormes montas nos jovens da sociedade, reduzo a pena base em 1/2, perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que " O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). O valor do dia multa será o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar VALTEMAR MACHADO SOUZA, como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto,

porque a despeito de se tratar de crime de tráfico, assemelhado aos crimes hediondos, não há indícios de que se trate de grande traficante. Ademais, foi solto no curso do processo, compareceu a todos os atos para os quais foi chamado, de maneira que faze-lo retornar aos sistemas carcerários mostra-se medida por demasiado extrema e desnecessária.

Não é possível, contudo, a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social.

Não é possível também a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social.

Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: “Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: “inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum).”

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida. Além disso, não encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício, uma vez que o crime em apreço possui natureza gravíssima, cujas circunstâncias caracterizadas pelo lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas de nossa sociedade, e as consequências do delito que levam à desestabilização familiar e social, indicam que a substituição não se mostra suficiente como forma de retribuição estatal.

De forma idêntica, a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, também não obsta aquele posicionamento, visto que o artigo 44, “caput”, da Lei de Tóxicos permanece íntegro. Trata-se ainda de crime equiparado aos crimes hediondos, não tendo assim, referida Resolução retirado o caráter hediondo do crime, circunstância que levou o legislador constituinte a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Declaro a perda do dinheiro em favor da União.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de setembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA